

1500651-84.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500651-84.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500651-84.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2072413/2022 - DEL.POL.SUZANO, 23631355 - DEL.POL.SUZANO, 129/22/320 - DEL.POL.SUZANO, 1065/22/309 - DEL.POL.SUZANO, 1068/22/309 - DEL.POL.SUZANO, 2072413 - DEL.POL.SUZANO, 2072413-02.2022.030309 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wesley Thiago Nunes e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de IRIS PEREIRA FABRÍCIO (nascida em 07/09/2001), WESLEY THIAGO NUNES (nascido em 23/08/1993) e JONATHAN PEREIRA REIS, devidamente qualificados nos autos, dados como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que, em 15/03/2022, por volta das 16h10, na Rua Manoel Ramos, nº 17, Parque Palmeiras, neste Município e Comarca de Suzano, os Réus, agindo em concurso entre si, guardariam e transportariam, para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 21 porções de maconha (41,32g), 08 porções de cocaína (2,42g) e 54 porções de crack

(8,82g).

Em 16/03/2022, em audiência de custódia, foi homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva em relação Réu Wesley e concedida liberdade provisória, com cautelares, aos outros Réus (fls. 88/95).

Comparecendo espontaneamente ao processo, os Réus Iris e Wesley apresentaram defesa prévia às fls. 160/166.

Em 04/07/2022, foi determinado o desmembramento do feito em relação ao Réu Jonathan, recebida a denúncia em relação aos Réus Iris e Wesley e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 183/184).

Em 04/10/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento, em que foram ouvidas testemunhas e interrogados os Réus, sendo declarada encerrada a instrução (fls. 225/226).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, com a condenação dos Réus, nos termos da denúncia (fls. 230/237).

Por sua vez, a Defesa aduz a nulidade do flagrante, por ter sido realizado por guardas municipais, usurpando função investigativa das forças de segurança pública. Requer a absolvição dos Réus, por ausência de prova e pela ausência de dolo.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o crime do art. 28, Lei nº 11.343/06, pela possibilidade de recorrer em liberdade, pela não fixação do regime inicial fechado e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 242/250).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada improcedente.

Conforme bem argumenta a Defesa, de rigor o reconhecimento da nulidade do flagrante, com a consequente anulação de todas as provas produzidas, eis que os guardas municipais que prenderam os Réus usurparam função investigativa exclusiva das forças de segurança pública e do Ministério Público.

O guarda municipal Ailton Avelino Castro Silva declarou que estavam saindo do Centro Cultural de Palmeiras, quando viram um Fiat/Palio preto dando seta e vindo na direção da viatura. Porém, ao avistar a viatura, o condutor fez o retorno bruscamente, o que lhes chamou a atenção. Seguiram em acompanhamento até um local mais calmo, onde foi dada ordem de parada, obedecida. Dentro do veículo estavam o Réu Wesley, dirigindo, a Ré Iris, no banco traseiro, e o Réu Jonathan, no banco do passageiro. Em revista pessoal nos homens, nada de ilícito foi encontrado. Todavia, o carro exalava um cheiro muito forte de drogas, o que motivou a busca veicular. Em uma sacola, que estava no assoalho do banco do passageiro, foram achadas as porções de crack, cocaína e maconha, além de três seringas com um líquido. Indagados, o Réu Wesley disse que achou a sacola no chão e a colocou dentro do carro, a Ré Iris disse que encontrou essa sacola com danones no chão e a pegou e o Réu Jonathan disse que desconhecia que a sacola estivesse no veículo.

O guarda municipal Cleiton Alan Correia Cordeiro prestou depoimento no mesmo sentido.

Quando interrogado em juízo, o Réu disse ser usuário de maconha e cocaína há anos. Na véspera, sua esposa saiu de casa com seu filho, razão pela qual comprou várias porções de maconha e cocaína e as consumiu e guardou no carro. No dia seguinte, ligou para sua esposa e decidiram retomar o relacionamento. No caminho para a casa da família da esposa, a Ré Iris, encontrou o Réu Jonathan e lhe deu uma carona. Pegou sua esposa e filho na casa da família dela e estavam a caminho de uma loja de roupas de criança. Estacionando o carro em frente à loja, foram abordados pelos guardas. Os guardas verificaram que o veículo estava com a documentação errada e que ele não era habilitado e disseram que apreenderiam o carro. Pediu para que eles não o fizessem, assim como sua esposa, sendo ambos ofendidos pelos guardas.

Exaltou-se e os ofendeu também. Nesse momento, eles acharam as drogas no porta-luvas. Inventou a história da sacola encontrada e dos danones porque estava com medo, desesperado e sob efeito de droga. Não conhecia os guardas. Não havia crack no veículo, tendo os guardas lhe dito que a quantidade de entorpecentes era pequena

e que, por isso, colocariam mais, para que fosse preso por tráfico. Os outros Réus não sabiam que havia droga no carro. Não havia odor de drogas. Em delegacia, negou a prática delitativa, dizendo que apanhou a sacola onde estavam as drogas e a colocou no porta-luvas do carro sem olhar o conteúdo (fls. 09).

Em seu interrogatório judicial, a Ré deu exatamente a mesma versão do primeiro Réu. Disse que mentiu aos guardas no desespero e que continuou mentindo em delegacia porque foi instruída a o fazer pelos guardas. Negou que a pessoa que estivesse com ela no depoimento fosse advogado, ou que tenha recebido qualquer orientação. Não combinou a história dos danos com o primeiro Réu, porque não se falaram desde a abordagem, permanecendo o tempo todo separados. Em delegacia, negou a traficância, apresentando a mesma versão do Réu, seu companheiro (fls. 08).

A prova constante dos autos, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidencia que os guardas civis municipais que prenderam os Réus investigaram eventual crime ou infração de trânsito, usurpando função das forças de segurança pública ou da autoridade de trânsito, agindo ilegalmente, portanto. Os agentes públicos, em suas oitivas, afirmam que viram o automóvel ocupado pelos Réus fazendo um retorno e, para verificar o motivo desse retorno, iniciaram acompanhamento e deram voz de parada mais à frente, em local mais tranquilo, quando, já realizada a abordagem, sentiram cheiro de drogas e resolveram realizar busca veicular. Ou seja, não havia situação nítida de flagrante quando do início da ação dos guardas municipais, eis que o que motivou a abordagem foi apenas o fato do veículo ter retornado em determinado ponto da via pública.

A Guarda Civil Municipal não integra as forças de segurança pública, conforme se extrai do art. 144, CF, que apenas prevê, em seu § 8º, a possibilidade de os Municípios instituírem guardas para a proteção de seus bens, serviços e instalações.

Na espécie, nenhum bem ou interesse municipal estava em jogo e os guardas não presenciaram qualquer situação flagrancial que poderia permitir a sua atuação como qualquer pessoa do povo, conforme acima exposto.

Não se olvida que há farta jurisprudência que legitima a prisão e as provas colhidas em razão de abordagens realizadas por guardas civis municipais em casos de tráfico de drogas, sendo, inclusive, aceita essa corrente por este Magistrado. Todavia, a aplicação dessa corrente jurisprudencial se funda única e exclusivamente na possibilidade de qualquer pessoa do povo prender outra em flagrante. Ou seja, para que a ação dos guardas civis municipais seja lícita, é preciso que exista estado flagrancial evidente, não que seja necessária investigação prévia a respeito do que está, de fato, acontecendo. Vendo esse retorno do veículo e suspeitando de eventual irregularidade administrativa ou criminal, deveriam os guardas municipais acionar a Polícia Civil ou a Polícia Militar, que têm atribuição constitucional para atuar na segurança pública.

Esse é o recente entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras “polícias municipais”, mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. A exclusão das guardas municipais do rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (incisos do art. 144 da Constituição) decorreu de opção expressa do legislador constituinte – apesar das investidas em contrário – por não incluir no texto constitucional nenhuma forma de polícia municipal.

2. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil – em contrapartida à possibilidade de exercerem a força pública e o monopólio estatal da violência – estão sujeitas a rígido controle correccional externo do Ministério Público (art. 129, VII, CF) e do Poder Judiciário (respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual). Já as guardas municipais – apesar da sua relevância – não estão sujeitas a nenhum controle correccional externo do Ministério Público nem do Poder

Judiciário. É de ser ver com espanto, em um Estado Democrático de Direito, uma força pública imune a tais formas de fiscalização, a corroborar, mais uma vez, a decisão conscientemente tomada pelo Poder Constituinte originário quando restringiu as balizas de atuação das guardas municipais à vigilância do patrimônio municipal.

3. Não é preciso ser dotado de grande criatividade para imaginar – em um país com suas conhecidas mazelas estruturais e culturais – o potencial caótico de se autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha sua própria polícia, subordinada apenas ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer controle externo. Ora, se mesmo no modelo de policiamento sujeito a controle externo do Ministério Público e concentrado em apenas 26 estados e um Distrito Federal já se encontram dificuldades de contenção e responsabilização por eventuais abusos na atividade policial, é fácil identificar o exponencial aumento de riscos e obstáculos à fiscalização caso se permita a organização de polícias locais nos 5.570 municípios brasileiros.

4. A exemplificar o patente desvirtuamento das guardas municipais na atualidade, cabe registrar que muitas delas estão alterando suas denominações para “Polícia Municipal”. Ademais, inúmeros municípios pelo país afora – alguns até mesmo de porte bastante diminuto – estão equipando as suas guardas com fuzis, equipamentos de uso bélico, de alto poder letal e de uso exclusivo das Forças Armadas.

5. A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem do suspeito.

6. Ao dispor no art. 301 do CPP que “qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes.

7. Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns. Trata-se de agentes públicos com atribuição sui generis de segurança, pois, embora não elencados no rol de incisos do art. 144, caput, da Constituição, estão inseridos § 8º de tal dispositivo; dentro, portanto, do Título V, Capítulo III, da Constituição, que trata da segurança pública em sentido lato. Assim, se por um lado não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro lado também não estão plenamente reduzidos à mera condição de “qualquer do povo”; são servidores públicos dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações.

8. É possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde municipais, de modo a garantir que não tenham sua estrutura física danificada ou subtraída por vândalos ou furtadores e, assim, permitir a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações. Nessa esteira, podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência

para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais – e por isso interpretadas restritivamente – nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária.

10. Na hipótese dos autos, os guardas municipais estavam em patrulhamento quando depararam com o recorrente sentado na calçada, o qual, ao avistar a viatura, levantou-se e colocou uma sacola plástica na cintura. Por desconfiar de tal conduta, decidiram abordá-lo e, depois de revista pessoal, encontraram no referido recipiente certa quantidade de drogas que ensejou a prisão em flagrante delito.

11. Ainda que eventualmente se considerasse provável que a sacola ocultada pelo réu contivesse objetos ilícitos, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado. Caberia aos agentes municipais, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas atribuições, acionar os órgãos policiais para que realizassem a abordagem e revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação do art. 244 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, também contrariado na hipótese.

12. Recurso especial provido” (STJ, REsp nº 1977119/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18/08/2022)

Em igual sentido, o seguinte precedente deste E. Tribunal:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca e apreensão. Guarda Municipal.

Atividade policial. Guardas civis não são, porque não devem mesmo ser, policiais.

Nossa ordem constitucional e legal é claríssima nesse sentido. Compete às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, o exercício da atividade de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, assim como compete às polícias militares a atividade de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública

(Constituição Federal, artigo 144, parágrafos 4º e 5º). Nesse sentido, prossegue o constituinte, as guardas municipais, constituídas pelos Municípios, estão nada mais que simplesmente destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações

(Constituição Federal, artigo 144, parágrafo 8º). Assim, se porventura a Guarda

Municipal receber informações que determinado veículo carregaria drogas, deve repassá-las de imediato à Polícia Civil ou à Polícia Militar que, do alto de sua

competência constitucional e legal, poderão, se o caso, tomar as providências

devidas. Não podem os guardas municipais, sob o argumento de dispor de tais informações ou denúncias anônimas, procurar por veículos na cidade e, avistando-os, determinar ao condutor respectivo? embora sem certeza visual alguma de crime, o que aí sim poderia ensejar a atuação de qualquer um do povo a parada imediata,

sujeitando, como se policiais fossem, seus ocupantes e o próprio carro a procedimento invasivo de revista. Se o fizerem, a prova assim obtida e toda a

investigação daí subsequente estarão contaminadas pela ilegalidade.” (TJSP, Apelação nº 0002974-40.2018.8.26.0079, Rel. Des. Sérgio Mazina Martins, 2ª Câmara de Dir. Criminal, j. 03/06/2019)

Dessa forma, reconhecida a ilegalidade do flagrante, todas as provas decorrentes da abordagem policial são nulas, o que gera à nulidade do auto de exibição e apreensão dos entorpecentes, dos consequentes laudos periciais, das oitivas de todos em

delegacia e em juízo, pois todas decorrem da primeira abordagem, ilegal. Assim, de rigor a absolvição dos Réus, por ausência de prova, na forma do art. 386, VII, CPP.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão acusatória e absolvo os Réus IRIS PEREIRA FABRÍCIO e WESLEY THIAGO NUNES, com fundamento no art. 386, IVI, CPP, da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Expeça-se imediato alvará de soltura do Réu Wesley, que deve ser imediatamente colocado em liberdade, salvo decisão em outro processo que tenha determinado sua prisão.

Revogo, também, as medidas cautelares impostas à Ré Iris, em conjunto com sua liberdade provisória.

Sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Com o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações necessárias.

Comuniquem-se à Vara de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação deste Estado e à Delegacia de Polícia de origem.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA